

1500861-43.2020.8.26.0637

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Anexo do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Anexo do Juizado Especial Criminal

Rua Colômbia, 200, Jardim América, Tupã - SP - cep 17605-900

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital:

1500861-43.2020.8.26.0637

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

OZEAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

Aos 13 de abril de 2022, às 10:00h, na sala de audiência virtual do Anexo do Juizado Especial Criminal do Foro de Tupã, Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, realizada neste formato de modo excepcional, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição e/ou impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, tudo conforme autorizado pelo E. Conselho Superior da Magistratura (Provimentos CSM nºs 2.554/2020 e 2.557/2020) e pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 314/2020), sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais foi constatada e certificada a presença no sistema virtual do DD. Promotor(a) de Justiça THIAGO ALVES DE OLIVEIRA, do(a) Dr(a). Defensor KELVIN AVALONE PEREIRA DO NASCIMENTO e do réu. Pelas partes inicialmente foi dito que não viam impedimento à realização do ato pelo sistema virtual. Foi oportunizado à Defesa o direito de contato reservado com o réu através do sistema virtual. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dada a palavra ao(à) Defensor(a), que assim se manifestou: "MM. Juiz(a), a Defesa do réu provará sua inocência no transcorrer do processo". Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferido o seguinte despacho: "Por haver indícios de autoria e prova da materialidade, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público e passo à instrução do feito". Na sequência, foi(ram) ouvida(s) 03 testemunha(s) do rol acusatório e o(a) réu(é) foi interrogado(a) sobre os termos da acusação, de acordo com o artigo 188, incisos I a VIII do CPP, mediante sistema de gravação de áudio e vídeo, na forma como autoriza o artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal. Fica consignado que a gravação desta audiência encontra-se disponível para consulta mediante acesso ao portal E-SAJ. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinada a realização dos debates, tendo sido dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que assim se

manifestou: “MM. JUIZ. O réu OZEAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR foi denunciado e está sendo processado pela prática do crime descrito no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, pois no dia 16 de agosto de 2020, por volta das 15h45, na Rua Abel Ferreira Leite, 833, Vila Tupã Mirim II, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, trazia consigo, para consumo pessoal, 08 (oito) pinos de cocaína, com peso líquido de 3,25g, conforme laudos periciais de fls. 08/13 e 29/31, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. A referida substância causa dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98. Foi designada AIJ, ocasião em que a denúncia foi recebida, bem como foi apresentada resposta à acusação e ouvidas as testemunhas arroladas pelo MP, sendo o réu interrogado. É o breve resumo dos fatos relevantes ocorridos, sendo dispensado o relatório em aplicação analógica do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Assim, vencida a fase instrutória, deve a pretensão acusatória ser JULGADA PROCEDENTE. Segundo o imputado na denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram um veículo Fiat Pálio, placas BLF-6990, estacionado ao lado da praça da Vila Marajoara, porém na contramão, motivo pelo qual resolveram realizar a abordagem dos ocupantes do automóvel. Ao se aproximarem, os policiais notaram que o passageiro do veículo “pulou” para o banco do motorista e passou a buzinar, a fim de chamar a atenção de seu colega que estava andando pela aludida praça. Diante disso, os milicianos abordaram o rapaz que andava pela praça, o qual foi identificado como sendo Ozéias Alves de Oliveira Junior, sendo localizado em poder dele 08 (oito) pinos de cocaína, os quais estavam no bolso de sua bermuda. A materialidade delitativa está demonstrada pela apreensão da droga demonstrada pelos laudos de fls. 08/09 e 29/31. A autoria, por sua vez, também é incontroversa. O policial militar William César disse estavam em patrulhamento no local e avistaram o veículo que estacionou na contramão o que motivou a abordagem. Com o réu localizaram as porções de entorpecente e o conduziram à delegacia. Ele disse que era usuário de drogas. O policial militar Rogério de Oliveira confirmou o relato de seu parceiro de farda. A testemunha Casimiro de Sousa disse que estava curtindo com o réu e as drogas se destinavam somente ao uso próprio dele, pois não usa. O réu confessou os fatos, admitindo que estava com as drogas para consumo próprio, pois na época era usuário. Destarte, inexiste razão para se duvidar das palavras dos policiais, pois “... não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeitem seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências” (RTJSP 417/94, 541/408, 574/401, 411/266, 416/96 e outras mais). Assim, não se pode colocar em dúvida a palavra dos agentes policiais, mormente quando contra a versão destes não se tem nenhuma prova. Neste sentido decidiu recentemente o STJ: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas

corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (Processo HC 201701464979 HC - HABEAS CORPUS - 404507 Relator(a) FELIX FISCHER Sigla do órgão STJ Órgão julgador QUINTA TURMA Fonte DJE DATA:18/04/2018). Pelo exposto, a prova oral produzida em contraditório e ampla defesa corrobora a prisão em flagrante do acusado de posse da substância entorpecente que era destinada ao seu próprio consumo. O réu é primário e portador de bons antecedentes, motivo pelo qual entendo suficiente a imposição da pena de advertência quanto aos efeitos nocivos das substâncias entorpecentes. Pelo exposto, requer seja julgada procedente a pretensão veiculada na ação penal, com a condenação do acusado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.". Dada a palavra à Defesa, assim se manifestou: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUPÃ/SP. Processo nº : 1500861-43.2020.8.26.0637. OZEAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, já qualificado nos autos do processo em epígrafe vem, com todo o respeito à presença de Vossa Excelência, por seu advogado infra-assinado, apresentar suas ALEGAÇÕES FINAIS, pelos fatos e fundamentos que seguem. DOS FATOS. Segundo o relatório fático contido na peça acusatória, o Ilustre representante do Ministério Público imputou ao acusado a prática do crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06. O feito encontra-se regular e sem nulidades. A denúncia foi recebida dos autos, apoiando-se nos depoimentos dos policiais que abordaram o acusado na via pública. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado. Segue nesta oportunidade os memoriais da defesa. Em breve resumo é o que traz os autos. DO DIREITO. Excelência, o acusado OZEAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, deve ser absolvido, pois a conduta praticada é atípica, senão vejamos. Primeiramente deve-se salientar que a conduta prevista hoje pelo artigo 28 da lei 11.343/06 não representa crime, uma vez que não há ofensa ao bem jurídico que supostamente visa a proteger, qual seja a saúde pública. Não apenas a doutrina enxerga a questão pelo viés descriminalizador, o próprio Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo emitiu decisão recente no sentido da descriminalização da posse de entorpecentes para consumo próprio. EMENTA: 1.- A traficância exige prova concreta, não sendo suficientes, para a comprovação da mercancia, denúncias anônimas de que o acusado seria um traficante. 2.- O artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é inconstitucional. A criminalização primária do porte de entorpecentes para uso próprio é de indisfarçável insustentabilidade jurídico-penal, porque não há tipificação de conduta hábil a produzir lesão que invada os limites da alteridade, afronta os princípios da igualdade, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada e do respeito à diferença, corolário do princípio da dignidade, albergados pela Constituição Federal e por tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil. (TJ/SP, Ap.Cr. nº. 01113563.3/0-0000-000, São José do Rio Pardo, 6ª Cam. C do 3º Grupo Sec. Crim.,

Rel. José Henrique Rodrigues Torres). Ainda nesse sentido: A posse de droga para consumo pessoal configura uma das modalidades do chamado delito de posse ("delitos de posesión"), que retrata uma categoria penal muito singular no Direito penal. Mister se faz, para a consumação da infração, constatar a idoneidade ofensiva (periculosidade) do próprio objeto material da conduta. Se a droga concretamente apreendida não reúne capacidade ofensiva nenhuma, em razão da sua quantidade absolutamente ínfima e da sua finalidade (uso pessoal), não há que se falar em infração (pouco importando a sua natureza, penal ou "para-penal"). Não existe, nesse caso, conduta penalmente ou punitivamente relevante. GOMES, Luiz Flávio. Drogas, Descriminalização e Princípio da Insignificância. Condenar o acusado pelo artigo 28 da lei de drogas é ferir o princípio da ofensividade, pois, o bem jurídico tutelado não oferece perigo para a sociedade, uma vez que sua quantidade é ínfima e o acusado informou que era para seu exclusivo uso. Visto que, o princípio da insignificância deve ser compreendido neste caso, pois a pequena quantidade, comprovada a utilização para uso próprio. Ademais, a previsão da posse de entorpecentes para consumo próprio tem de ser encarada como ofensiva ao princípio constitucional da igualdade, do Estado de inocência e da ofensividade vez que trata de formas diferentes usuários de substâncias entorpecentes lícitas e ilícitas, as quais causam igualmente vínculos de dependência. A norma penal incriminadora tem a sua razão de ser na proteção de um bem jurídico, excluindo de seu âmbito de

proibição as condutas que não afetam o bem juridicamente tutelado. Insta Salientar o princípio da proporcionalidade, onde o entorpecente, diga-se de passagem, de ínfimo valor, portanto, a consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais - assim sustentava Welzel - ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material - STF, HC 84.412, rel. Min. Celso de Mello), consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouca importância ou de ínfima lesividade. São fatos materialmente atípicos (afasta-se a tipicidade material, pouco importando se trata da insignificância da conduta ou do resultado). Portanto, Excelência, não há dúvida que, por força do princípio da insignificância, o fato mínimo ou de ínfimo significado é atípico, seja porque não há desaprovação da conduta (conduta insignificante), seja porque não há um resultado jurídico valioso (resultado ínfimo). A afetação insignificante, portanto, exclui a tipicidade, devendo ser estabelecida através da consideração conglobada da norma, ou seja, a insignificância surge à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa, não podendo ser estabelecida de uma consideração isolada da norma. Inclusive em matéria de entorpecentes, apesar das divergências (que continuam), são numerosas as decisões do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo o princípio da insignificância: "Entorpecente. Quantidade ínfima. Atipicidade. O crime, além da conduta, reclama um resultado no sentido de causar dano ou perigo ao bem jurídico (...); a quantidade ínfima informada na denúncia não projeta o perigo reclamado".¹ Sempre "é importante demonstrar-se que a substância tinha a possibilidade para afetar ao bem jurídico tutelado".² A pena deve ser "necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Quando a conduta não seja reprovável, sempre e quando a pena não seja necessária, o juiz pode deixar de aplicar dita pena. O Direito penal moderno não é um puro raciocínio de lógica formal. É necessário considerar o sentido humanístico da norma jurídica. Toda lei tem um sentido teleológico. A pena conta com utilidade".³ "Trancamento de ação penal, crime, porte de entorpecente, maconha, pequena quantidade, inexistência, dano, perigo, saúde pública, aplicação, princípio da insignificância. (voto vencido) (min. Paulo Gallotti) descabimento, trancamento de ação penal, crime, porte de entorpecente, maconha, uso próprio, hipótese, consumo, praça pública, irrelevância, pequena quantidade, caracterização, tipo penal, perigo abstrato, violação, saúde pública." (STJ, HC 21672-RJ, Rel. Min. Fontes de Alencar). "Penal. Entorpecentes. Princípio da insignificância. - sendo ínfima a pequena quantidade de droga encontrada em poder do réu, o fato não tem repercussão na seara penal, à míngua de efetiva lesão do bem jurídico tutelado, enquadrando-se a hipótese no princípio da insignificância - habeas corpus concedido. (STJ, HC 17956-SP, rel. Min. Vicente Leal). Por todo o exposto, é de rigor a aplicação do princípio da insignificância no caso dos autos. Destarte, como não estamos de uma situação clara, inequívocas, a condenação da ora apelante não pode e não deve persistir, eis que tal decisão afronta demasiadamente todos os preceitos constitucionais mais basilares, tais como a dignidade da pessoa humana, bem como a aplicação basilar do estado constitucional de inocência. Diante do exposto, requer-se a absolvição do acusado, ante a ATIPICIDADE DE CONDUTA, no que diz respeito às ameaças com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. DO PEDIDO. Ante todo o exposto, requer que seja o acusado OZEAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, ABSOLVIDO pela atipicidade de conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pelos motivos de fato e de direito aqui expostos." Após, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Vistos. Dispensado o relatório em virtude de disposição expressa da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade do crime restou comprovada pelo termo circunstanciado, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 01/03), pelo exame químico-toxicológico (fls. 08/10 e 29/31) e pela prova oral produzida. Passo à análise da autoria. O depoimento dos agentes públicos, em Juízo, corroborado pela apreensão da droga em seu poder, são suficientes para comprovação de forma segura e robusta a autoria delitiva do réu. Os elementos colhidos em solo policial corroboram as provas produzidas, reforçando-as. O acusado foi interrogado e disse que a droga era para seu consumo. Assinou seu depoimento à fl. (05). Aliás, nada há nos autos a demonstrar tendência odiosa em incriminar falsamente o réu. Assim,

levando-se em consideração os critérios estabelecidos no art. 28, § 2º da Lei 11.343/2006, dadas as circunstâncias em que os fatos estão envoltos, o depoimento dos policiais e sua harmonia com os elementos colhidos em solo policial, bem como a pequena quantidade de droga que o réu trazia consigo, o que indica o consumo próprio, não há dúvidas de que o acusado trazia consigo para consumo pessoal a droga apreendida. Ademais, não há se falar em eventual absolvição em nome do abstrato princípio da insignificância ou mesmo de ocorrência da "abolitio criminis", isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicóticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT 676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306), mesmo porque "não se pode, a pretexto de adequar a lei à realidade social nova, relega-la a segundo plano, posto o que se quer é que o juiz, ao aplicar a lei à espécie, considere o fim social a que se destina a norma e as exigências do bem comum. Pretender-se a não aplicação da lei, pura e simplesmente, sob a desculpa de que não se compatibiliza com a nova realidade social seria rematado absurdo, pois, em tal situação, cabe ao juiz temperar o rigor da lei, na medida do possível, sem distorcê-la, sem desnaturá-la, lançando mão do instrumental jurídico de que dispõe, para alcançar o fim colimado" (RT 569/348), não dando azo, nem mesmo, a se falar em estado de necessidade em razão de eventual dependência à época (JTACrimSP 34/388). No mais, não há porque se declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que tendo em vista que o dispositivo não perdeu sua eficácia e seu vigor, continuando sendo considerado como crime, tendo apenas sanções alternativas. Confira-se: "APELAÇÃO CRIMINAL. Porte de droga para consumo - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Não caracterização do delito de tráfico de drogas - Constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Decisão condenatória que se impõe - Pena adequada - Recurso não provido." (TJ/SP - Apelação nº 0001252-11.2009.8.26.0006, relator Desembargador Ricardo Sale Júnior, julgado em 05/03/2015 - grifo não existente no original). A multa a que se refere o artigo 29 será apreciada no caso de eventual descumprimento da pena. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação é de rigor. Passo à dosimetria da pena. Considerando a circunstâncias do caso, aplico a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas. Isso visando à prevenção e ressocialização do acusado, porquanto entendo que a pena aplicada cumpre as referidas finalidades. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu OZEAS ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 2) Promovam-se as anotações de estilo; 3) Expeçam-se as comunicações necessárias. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. As partes requereram a renúncia do prazo recursal. Pelo MM. Juiz foi dito o seguinte: "Homologo a renúncia do prazo recursal; tendo em vista trânsito em julgado ter ocorrido nesta data, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado." Fica consignado que a advertência foi realizada na própria audiência, mediante termo próprio. Tendo sido a audiência realizada por videoconferência, ao final o presente termo foi exibido às partes, que concordaram com seus termos, ficando dispensada as assinaturas. Nada mais havendo, foi encerrada a audiência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Diego Vicentim Januário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006